

势及持股优势，连续买卖股票，操纵证券交易价格和交易量，情节特别严重，其行为均已构成操纵证券市场罪；违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营证券业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。李某某全程参与并策划、指挥本案操纵证券市场及非法经营行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；邱某某按照李某某的指令安排他人操作证券账户、监管配资账户、提供证券经纪服务等，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。李某某、邱某某到案后能够如实供述操纵证券市场的犯罪事实，均具有坦白情节。综合考虑李某某、邱某某的认罪悔罪态度，退赔部分钱款等事实、情节，对其从宽处罚的辩护意见。据此，判决如下：

一、被告人李某某犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币1000万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币200万元，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币1200万元；

二、被告人邱某某犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币60万元；

三、违法所得予以追缴，犯罪工具予以没收。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理操纵证券、期货市场刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，操纵证券市场的违法所得是指通过操纵证券场所获利益或者避免的损失。

一、操纵证券市场违法所得的期间认定

操纵行为获利的本质是通过扭曲市场价格机制收益，因此，应当将证券交易价量因操纵行为受到影响的期间，作为违法所得计算的依据，行为人在该期间的不法获利即为违法所得。在判定操纵期间时，需要关注行为人持有涉案股票的时间段内，该股在日收益率、有效价差、换手率和交易规模等市场指征方面的异常表现，以异常交易日作为关键时间节点，结合证人证言、被告人供述

等在案证据综合判断行为人是否具有操纵的主观故意，以主客观相统一的原则判定。

操纵终止日原则上以操纵影响消除日认定，即便此前操纵行为已经停止，只要市场股价波动仍与操纵行为存在因果关系，行为人仍应对后续产生的影响负责。但在交易型操纵犯罪中，操纵行为可能因行为人被采取刑事强制措施而中断。考虑到行为人此时已无法继续滥用优势控制市场，以操纵行为结束日作为操纵终止日更能体现操纵行为与市场影响的因果关系。

二、操纵证券市场违法所得的内容涵摄

操纵证券市场的不法获利主要包括交易价差、余券收益等。关于交易价差，对于已出售的股票，收益应为卖出价与买入价的差值。关于余券收益，在涉案账户仍持有余券的情况下，期末余券的获利也应当计入违法所得金额。

违法所得的计算过程中，还应合理确定金额扣减因素。首先，操纵证券市场犯罪中受其他市场因素影响产生的获利原则上不予扣除。证券市场中股价变动往往是多种因素共同作用的结果，某一项因素产生的具体影响难以被准确界定。民事案件中采取的是高度盖然性证据标准，法院可就双方举证情况，对其他市场因素导致的不法获利数额进行自由裁量。但刑事案件的事实查明有更严谨的要求，对市场因素影响不宜采取估算的方式。且行为人在实施操纵行为时，对于其他市场因素会导致价格波动有主观明知，亦是试图通过操纵行为与其他市场因素的交织对证券市场产生影响并从中获利。因此，在刑事案件中，受其他市场因素影响产生的获利原则上不予扣除。其次，交易费用属于证券市场中合法合理的手续费用，并非操纵行为影响下优势滥用的价值转化，应在计算时予以扣除。

三、操纵证券市场违法所得的适用场域

在以违法所得对犯罪情节进行评价时，应当严格遵循“优势滥用的经济价值转化”原则，将违法所得金额限定为操纵期间内的不法获利，以体现对操纵行为危害结果的客观评价。而在以违法所得对行为人进行财产追缴时，则需按照亏损产生的具体原因区分认定应追缴的违法所得金额。对于因行为人自身原

因导致股票未能及时抛售的，对其以操纵期间的获利金额进行追缴。对于因侦查行为等客观因素导致股票未能及时抛售的，剔除终止日后形成但与操纵行为密切关联的余券亏损，以客观获利实际为依据对行为人追缴违法所得，避免过度追缴。

编写人：上海市第一中级人民法院 李长坤
吕昱清

40

骗购外汇与逃汇行为交织时的司法认定

——A 公司等骗购外汇、逃汇案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市中级人民法院 (2023) 闽05刑终359号刑事判决书

2. 案由：骗购外汇罪、逃汇罪

【基本案情】

2010年至2013年，被告人苏某作为A公司、B公司、C公司的实际经营者、直接负责的主管人员，利用虚假的海关保税区进境货物备案清单、货权证明等材料，虚构转口贸易业务，以上述公司名义或委托其他公司通过向银行申请信用证，信用证到期后向境外公司付汇，付汇来源为自有外汇及以同样事由向银行申购的外汇。经查，三被告单位以上述手段共计付汇达478990840.07美元，其中包含向银行骗购的外汇156996139.17美元。

被告人苏某对上述犯罪事实供认不讳，还如实供述公安机关尚未掌握的其利用A公司、B公司、C公司等企业进行的其他逃汇犯罪事实。

【案件焦点】

骗购外汇罪与逃汇罪的行为交织重叠时，对以逃汇为目的的骗购外汇行为，应当适用牵连犯择一重罪原则按骗购外汇罪定罪量刑，而对以自有外汇逃汇的，应当认定为逃汇罪，由于两部分犯罪行为不完全重合，对该两部分行为是否应当实行数罪并罚。

【法院裁判要旨】

福建省石狮市人民法院经审理认为：被告单位A公司、B公司、C公司违反国家规定，虚构转口贸易，致使境内外汇被非法转移至境外，逃汇数额分别为240093740.47美元、38214001.6美元、200683098美元；上述逃汇数额中，分别有68837395.5美元、15532378.55美元、72626365.12美元系以虚假的海关单据、货权证明等凭证骗购的外汇，三被告单位的行为均已构成逃汇罪和骗购外汇罪，均属逃汇数额巨大、骗购外汇数额特别巨大；被告人苏某作为上述三被告单位的实际经营者，属单位犯罪中直接负责的主管人员，其行为亦构成逃汇罪和骗购外汇罪，属逃汇数额巨大、骗购外汇数额特别巨大。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十条，第六十九条，第六十七条第二款、第三款以及《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条第一款的规定，判决如下：

一、被告单位A公司犯逃汇罪，并处罚金人民币5500万元；犯骗购外汇罪，并处罚金人民币2200万元，决定执行罚金人民币7700万元；

二、被告单位B公司犯逃汇罪，并处罚金人民币730万元；犯骗购外汇罪，并处罚金人民币500万元，决定执行罚金人民币1230万元；

三、被告单位C公司犯逃汇罪，并处罚金人民币4100万元；犯骗购外汇罪，并处罚金人民币2400万元，决定执行罚金人民币6500万元；

四、被告人苏某犯逃汇罪，判处有期徒刑五年；犯骗购外汇罪，判处有期徒刑十年，决定执行有期徒刑十二年。

一审宣判后，A公司、B公司、C公司、苏某提出上诉。

福建省泉州市中级人民法院经审理认为：上诉单位A公司、B公司、C公

司违反国家规定，虚构转口贸易，致使境内外汇被非法转移至境外，逃汇数额分别为240093740.47美元、38214001.6美元、200683098美元；上述逃汇数额中，分别有68837395.5美元、15532378.55美元、72626365.12美元系以虚假海关单据、货权证明等凭证骗购的外汇，三上诉单位的行为均构成逃汇罪和骗购外汇罪，均属逃汇数额巨大、骗购外汇数额特别巨大；上诉人苏某作为三上诉单位实际经营者，属单位犯罪中直接负责主管人员，其行为亦构成逃汇罪和骗购外汇罪，属逃汇数额巨大、骗购外汇数额特别巨大。A公司、B公司、C公司及苏某均犯有数罪，应当实行数罪并罚。B公司、C公司具有自首情节，分别予以从轻处罚。苏某归案后如实供述犯罪事实，对A公司及苏某分别予以从轻处罚。三上诉单位部分涉案外汇已收回，对三上诉单位及苏某分别酌情从轻处罚。三上诉单位因本案被行政机关处罚所缴纳罚款应在本案判处罚金时予以抵扣。原判定罪及适用法律准确，对三上诉单位判处罚金适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二项的规定，判决如下：

一、驳回上诉单位A公司、B公司、C公司上诉，维持福建省石狮市人民法院(2022)闽0581刑初76号刑事判决的第一项、第二项、第三项；

二、撤销福建省石狮市人民法院(2022)闽0581刑初76号刑事判决第四项中对上诉人苏某量刑部分的判决；

三、上诉人苏某犯逃汇罪，判处有期徒刑五年；犯骗购外汇罪，判处有期徒刑十年，决定执行有期徒刑十年六个月。

【法官后语】

《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》是我国一部单行刑法。近年来，跨境资金流动的不确定性增大，外汇违法犯罪活动明显上升，利用虚构转口贸易新型犯罪案件频发，犯罪模式的变化给刑事司法的事实认定、法律适用带来了挑战，相关法律问题亟待研究和解决。

一、骗购外汇罪的司法认定

本案中，三被告单位及被告人苏某利用虚假的海关保税区进境货物备案清

单、货权证明等材料，虚构转口贸易业务向银行申购外汇的行为，逃汇数额多达478990840.07美元，但既没有伪造、编造报关单、进口证明，也没有使用外汇管理部门核准件，该行为是否属于“以其他方式骗购外汇”值得研究。

首先，外汇犯罪是典型的行政犯，需要考察是否违反前置行政法的规定。《中华人民共和国外汇管理条例》第四十条规定，以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，应予以行政处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。本案中，三被告单位及被告人苏某使用虚假的进境货物备案清单、货权证明等材料到银行购汇，属于该条款中的非法套汇行为，具有前置的行政法依据。

其次，兜底条款所涉内容必须与刑法明示内容具有同质性。对于经济犯罪兜底条款所涉的符合构成要件的行为判断，必须是行为人的行为与构成要件所要求的内容具有行为的同质性。从客观行为来看，本案中三被告单位及被告人苏某用以购汇的进境货物备案清单、货权证明等材料均是虚假的。从主观故意上看，三被告单位及被告人苏某是利用虚假转口贸易购买外汇，其主观上是积极追求犯罪的直接故意。从危害后果上看，利用虚假转口贸易购买外汇与伪造、变造或者重复使用相关凭证、单据一样，均破坏了外汇管理秩序。因此，本案中行为人虚构转口贸易到银行购汇的行为与《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》明示的行为方式具有同质性，应当认定为骗购外汇罪。

二、逃汇罪的司法认定

本案中三被告单位及被告人苏某以虚假材料向银行申请外汇，但其目的并非单纯地将外汇资金转移至境外，而是为了套用银行外汇周转资金、储备境外资金等，其付汇的大部分外汇有回流，此种行为将外汇转移至境外后再收汇入境，与传统的逃汇行为有所区别。我们认为，以虚假转口贸易将外汇资金转移境外时逃汇行为已经既遂，行为人转移外汇后再收汇入境的行为不影响逃汇罪的认定理由如下：

首先，从保护法益的角度来看，该行为侵害了国家外汇管理制度。《中华

